

1500212-22.2022.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... receberam denúncia da ocorrência de tráfico de entorpecentes na Av. Tamoios em Itanhaém/SP. Em campanha pelo local, fora possível identificar duas pessoas que estariam em atitude típica de tráfico, e que posteriormente foram identificados como sendo o réu e o menor. Informou que visualizaram Wesley adentrando um imóvel e retornando, pouco tempo depois, com uma sacola em mãos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500212-22.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Reqte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

WASHINGTON LUIS CARDOSO DA SILVA

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

WASHINGTON LUIS CARDOSO DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 15 de junho de 2022, por volta das 16h51min, na Av. Tamoios, próximo ao pesqueiro, Balneário Tupy, nesta cidade e comarca de Itanhaém, o agente supra apontado, agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente infrator WESLEY CARDOSO DA SILVA, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesseis) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, totalizando peso de 3144,48 g, 02 (dois) papелotes de cocaína e 14 (catorze) pedras de crack, derivado da cocaína, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14.07.2022 (pág. 108).

O réu foi citado (pág. 137) e apresentou resposta escrita à acusação (págs. 143/146).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do réu (págs. 171/172).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos às págs. 98/10.

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-o nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou subsidiariamente, que seja aplicada a pena mínima, sem a causa de aumento do artigo 40, com a fixação do regime semiaberto.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04/05), pelo boletim de ocorrência (págs. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 21/22), pelo auto de constatação preliminar (págs. 23/24), pelo laudo pericial (págs. 133/135), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e atribuída ao acusado.

A testemunha arrolada pela acusação, João Paulo da Silva Pires, Policial Civil, ouvido em Juízo, relatou que receberam denúncia da ocorrência de tráfico de entorpecentes na Av. Tamoios em Itanhaém/SP. Em campanha pelo local, fora possível identificar duas pessoas que estariam em atitude típica de tráfico, e que posteriormente foram identificados como sendo o réu e o menor. Informou que visualizaram Wesley adentrando um imóvel e retornando, pouco tempo depois, com uma sacola em mãos, a entregando a Washington, o qual pegou algo da sacola e forneceu a terceiros. Em vista da situação constatada, realizaram a abordagem e de ilícito com eles nada fora encontrado, contudo, no matagal, encontraram a sacola com cocaína e maconha. Indagados sobre quem morava na residência, o réu alegou que ali residia, indicando onde havia mais entorpecentes, momento em que foram localizados alguns tijolos de maconha.

A testemunha arrolada pela acusação, Carlos Henrique Estefane da Hora, Policial Civil, ouvido em Juízo, relatou os mesmos fatos que seu colega de profissão.

Não há razão suficiente a invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"A alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-la, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar os réus. Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa da natural apenas com o intuito de justificar as suas ações. E, pequenas divergências existentes entre as declarações prestadas pelos policiais militares não bastam, por si sós, para infirmá-las. 'O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes

olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 Relator Des. Pinheiro Franco 5ª Câmara V.U. 31.07.2008)'. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição. Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111) 'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

O réu, Washington Luis Cardoso Da Silva, interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva. Disse que ganhou cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais) para guardar os entorpecentes.

Pois bem.

A responsabilidade penal do réu é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pelo laudo pericial, auto de exibição e apreensão e a confissão espontânea, somados aos depoimentos, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar as condutas do réu, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) As vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACrim-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Ademais, a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas é de rigor, uma vez que a prova produzida não deixou dúvida acerca do efetivo envolvimento do adolescente no tráfico de drogas, conforme narrado pelos policiais.

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do réu, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir suas responsabilidades penais. Imperiosa, pois, a condenação.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes do réu (págs. 68/77), observo que o mesmo não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.[...]" (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, como também a agravante da reincidência, conforme certidão (págs. 78/81), que é considerada preponderante sobre a atenuante conforme regra expressa do artigo 67 do Código Penal. Diante disso, exacerbo a pena base em apenas 1/3 (um terço), resultando uma pena provisória de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete dias) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento de pena prevista do no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em uma pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1036 (mil e trinta e seis) dias-multa.

Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes".

Desta forma, o réu sendo reincidente impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

Dito isso, presente a agravante da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), pela suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I e III do Código Penal), e a aplicação dos regimes aberto e semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e "c" do Código Penal), em razão da pena imposta conforme artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal) o qual informa que em pena superior a 08 (oito) anos o regime inicial é o fechado.

Posto isto, CONDENO o réu WASHINGTON LUIS CARDOSO DA SILVA qualificado nos autos, ao cumprimento de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1036 (mil e trinta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C- Arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 30 de novembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA